

1500172-61.2021.8.26.0605

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Também presente a causa de aumento da interestadualidade, vez que objetiva e porque o réu vinha de Três Lagoas/MS, onde havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500172-61.2021.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-61.2021.8.26.0605

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2146201/2021 - DEL.SEC.ANDRADINA, 18209903 - DEL.SEC.ANDRADINA, 701/21/100 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2146201 - DEL.POL.CASTILHO, 701/21/100 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ EDGARD MACHADO CONTIERO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LUIZ EDGARD MACHADO CONTIERO imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 29 de maio de 2021, por volta das 21h57min, na base de pedágio de Castilho, localizada na Rodovia Marechal Rondon, naquela cidade, nesta comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.09, 21, 31, 34, 39 e 46 dos presentes autos, adquiriu em outro Estado da Federação, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 04 porções de "maconha", sob a forma de "skank", com peso aproximado de 273,46g (cf. autos de constatação provisórios de fls.12/13, 14/15, 16/17 e 18/19), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em fls 157/160. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa,

por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito, além de outros pedidos com relação à aplicação da pena (redutor do § 4º, regime, patamar etc).

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls 01/02 ; boletim de ocorrência de fls.03/06 , autos de exibição e apreensão de fls10/11, laudos periciais de fls.12/19, 250/251, relatório de fls. 287/303), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

O policial militar Alexandre Luiz Ribeiro narrou que estavam em serviço "de força tática" por Castilho. Abordaram um ônibus que faz trajeto de Três Lagoas-MS a São Paulo. Em busca, abordaram o indivíduo identificado como Luiz. Nada localizaram com ele. AO verificar a bolsa, localizaram um cigarro de maconha (skunk). Ele falou que seria usuário e traria uma quantidade no bagageiro. Confirmaram o comprovante de bagagem e acharam uma bolsa de cor verde. Localizaram mais drogas, tudo totalizando 261 gramas. Ele falou que não seria a primeira vez que levaria as drogas para SP, dizendo que paga 4,00 em Três Lagoas e compra em SP por 20 reais. Ele falou que estava levando para consumo próprio. Segundo ele não era a primeira vez. Ele é morador de SP e prestava serviços em 3 Lagoas.

Robson Novaes Diletti ,policial militar, confirmou a versão de seu colega.

A testemunha de defesa Marcos Daniel disse que conhece o Edgar desde fevereiro deste ano. Conheceu ele na faculdade. Ele era seu veterano. Moram juntos desde março de 2021. Nunca teve conhecimento de que ele praticou tráfico. Sabia que ele usava maconha. Tinha um acordo dele não usar em casa. Ele usava dia sim, dia não, mais dia de semana. De fim de semana era mais comum ele usar. Durante a semana menos, porque ele trabalhava. Todos estudam à noite. Ele era bastante assíduo nas aulas. Cada um tem seu quarto na casa. O curso é de ciências contábeis. Sabe que ele usa droga, mas ele não usa dentro de casa. Ele usa maconha. Que saiba ele só usa maconha. Não faz ideia de onde ele compra. Ele é de Mogi das Cruzes. Essa foi a primeira vez que ele foi viajar. Foi a primeira vez que viu ele viajando. Desde que mudou, ficaram na casa "frequentemente". Nunca teve movimentação estranha de pessoas procurando o Luiz.

A testemunha de defesa Marcos Rogério Gomes disse que o réu é namorado de sua filha. Receberam a notícia com surpresa. Ele sempre trabalhou e estudou.

O réu negou o tráfico. Disse que a droga destinava a seu consumo. Afirmou fumar cerca de um "baseado" por dia, mas aos fins de semana usa mais.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese houve apreensão de relevante quantidade de maconha (cerca de 272 gramas), transportada pelo réu entre as cidades de Três Lagoas/MS e Mogi das Cruzes/SP. Ainda que o réu se diga compulsivo usuário de maconha, a quantidade apreendida é bastante expressiva. Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente (TJSP, Acr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). Conclui-se que, com a quantidade apreendida, seria possível confeccionar de 270 a 540 cigarros, o que parece ser exorbitante, mesmo para um usuário frequente.

E a justificativa do réu cai por terra diante relatório de fls. 287/303. As imagens

ali retratadas indicam que o réu não se trata de mero universitário que consome drogas de forma contumaz. Trata-se, sim, de universitário que também trafica, além de ostentar típico comportamento de quem o faz.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas (e universitário) e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente universitário e usuário de drogas, isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. É também comum a figura do estudante que pratica o delito no próprio meio universitário ou que vende drogas a amigos de forma cotidiana, como forma de angariar recursos em nível superior àquele auferido com os estágios e trabalhos típicos da época estudantil. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Também presente a causa de aumento da interestadualidade, vez que objetiva e porque o réu vinha de Três Lagoas/MS, onde havia adquirido a droga.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas

máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais".

E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, deixo de valorar a quantidade de droga como circunstância negativa, pois utilizada como critério preponderante para estabelecimento da própria tipicidade do fato. A natureza da droga, ainda que se trate de skunk, não é apta a recomendar sanção mais gravosa. Fixo a pena no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e eventuais atenuantes esbarram na súmula 231 do STJ.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, por

conta da clara dedicação às atividades criminosas, retratada no relatório de fls. 287/303, no qual o acusado envia e recebe fotos pesando entorpecentes, ostentando dinheiro em espécie, arma de fogo e grandes quantidades de maconha (em "peças" e a granel). A quantidade de entorpecente apreendida também é indicativo desta dedicação.

Neste ponto, anoto que para aplicação da causa de diminuição em questão não basta a primariedade, que não conduz automaticamente à aplicação do redutor. Caso esteja comprovado que o acusado se dedica a atividades criminosas, mesmo primário, não receberá o benefício legal.

E a interpretação de que o redutor deve ser aplicado, sem maiores critérios, a todo réu primário não é a mais adequada aos fins da Lei 11.343/06 e à própria Constituição (a qual deu tratamento bastante enfático e especial a este crime, o estabelecendo como um dos mais graves de nosso ordenamento - vide artigos 5º, XLIII e LI, 144, II e 243, parágrafo único).

Com efeito, caso o réu primário dedique-se a atividades criminosas, deve-lhe ser negada a aplicação do redutor. Em outros termos: o redutor somente é cabível àquele que pratica o tráfico de forma episódica, eventual, como um desvio em seu caminho e não como um padrão de vida, ainda que a conduta não se revista de gravidade comparável à das grandes organizações (para estas, a lei reservou pena de até 15 anos de reclusão, além das penas da associação criminosa).

De outro lado, presente a causa de aumento da interestadualidade, devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Sendo assim, a pena fica em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo, para tanto, o magistrado observar as regras previstas nos arts. 33 e 59 do Código Penal (Nesse sentido: HC 234025/SP, Rel. Ministro Ericson Marinho, Desembargador Convocado do TJSP, DJE 15/10/2015).

Assim, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado, a gravidade do fato e a causa de aumento, entendo que o regime adequado para o início de cumprimento da pena é o intermediário, ou seja, o semiaberto. Não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional do processo, pois tais medidas não se mostram suficientes para a repressão/prevenção do crime, tampouco se mostram socialmente recomendáveis no caso concreto. Além disso, a pena aplicada não permitiria os benefícios.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO LUIZ EDGARD MACHADO CONTIERO, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

Permito recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 14 de fevereiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)